

רשות ערעור אזרחי מס' 4928/92

א

1. יחזקאל עזרא

2. טובה עזרא

3. עוזי עזרא האג'

ב

4. אנגל עזרא

5. אהרון עזרא

6. יעקב עזרא

7. נעמי עזרא

ג

8. עמי בוארון

נגד

המועצה המקומית תל-מונד

ד

בבית המשפט העליון בטבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

[24.5.93]

ה

לפני הנשיא מ' ש מ ג ר והשופטים א' גולדברג, ד' דורנר

תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, ק"ת 2220, תקנה 410 – חוק הבוררות, תשכ"ח-1968, ס"ח 184, סעיפים 1, 39 – חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, ס"ח 267 – דבר המלך במועצה על ארץ-ישראל, 1922, חא"י כרך ג, (ע) 2738, (א) 2569, סימן 46 – חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, ס"ח 118, סעיפים 12, 39, 61(ב) – חוק הביטוח העותמני, סעיף 2.

ו

המבקשים החזיקים בנכס המצוי בבעלות המשיבה. הנכס נמסר להם על-ידי אדם שחברו מהמשיבה למשך 25 שנה. בהיות התכירה התחייב החוכר להקים על הקרקע מבנה ולנהל בו מסעדה וכית-קפה בלבד, ולמשיבה ניתנה הברירה בתום תקופת התכירה להאריכה או לשלם לחיכר את שווי המבנה והעסק. המבקשים ניהלו במבנה שהקים החוכר עסק של מכירת מצרכי מזון וחומרי ניקוי ללא רישיון. הם הועמדו לדין על כך, הורשעו ונצטוו לסגור את עסקם, אם לא יינתן להם היתר כחוק עד למיעד מסוים. המשיבה לא האריכה את תקופת התכירה ודרשה בהמבקשים לפנות את הנכס ולשלם לה עבור התקופה שהחזיקו בו דמי שכירות ראויים. המבקשים תבעו, כתנאי לפינוי הנכס, את תשלום שווי המבנה והעסק. הסכום הועבר בהסכמה להכרעת בורר. בכתבי הטענות נדרש הבורר להכריע במלוייה עניינים: (א) זכות המבקשים בנכס; (ב) זכות המשיבה לדמי שימוש ראויים, תקופת החיוב וסכומה; (ג) שווי המבנה והעסק המתנהל בו ללא רישיון. במהלך הדיון צמצמו הצדדים את סמכות הבורר

ז

להכרעה בזכויותיהם ולמתן הוראות לשמאים כיצד להעריך את חיוביהם, ואילו את קביעת גובה הסכומים, על-פי הנחיות הבורר, מסרו לשמאים. הבורר קבע כי המבקשים החזיקו כדין בנכס עד לתום תקופת החכירה ומאותו יום עליהם לשלם דמי שימוש ראויים, והוא חייב את המשיבה לשלם למבקשים את שווי המבנה והעסק. למרות שבהסכם הבוררות נאמר כי הבורר יקבע את שווי העסק, הוא ראה שלא להורות על הערכת עסק המנוגד לחוקי הרישוי ולמטרת החוזה והורה לשמאים להעריך את שווי המבנה ועסק של בית-קפה ומסעדה קלה – אילו היה מתקיים במקום זה באותו מועד. באי-כוח המשיבה כתב לבורר וציין לפניו שלא הייתה הכרעה בעניין הכספי המעשי שהועבר להכרעת שמאי הצדדים. שמאים אלה לא הגיעו להסכמה. בעקבות זאת התחדש הדיון, והבורר קבע את גובה שווי העסק ובפסק משלים קבע גם את גובה דמי השכירות הראויים. בהסכמת הצדדים בוטל הפסק המשלים, ובבית המשפט המחוזי נדונה בקשת המשיבה לביטול קביעת הבורר בדבר שווי העסק. בית המשפט המחוזי קיבל את הבקשה. מכאן הבקשה לרשות ערעור שנדונה כערעור.

בית המשפט העליון פסק:

א. (1) אין לו לבורר כוח שיפוטי, זולת הכוח שהקנו לו הצדדים בהסכם הבוררות. בכך נבדל הבורר מבית המשפט, שכוחו אינו תלוי בהסכמת הצדדים אלא קבוע בחוק. אמנם, הצדדים אינם מוגבלים בבחירת הצורה של הסכם הבוררות, ואף הסכם בוררות שנעשה בעל-פה הוא תקף (סעיף 39 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968). ברם על-פי סעיף 1 לחוק, חלות הוראות חוק זה על הסכם בכתב בלבד. מכאן שהסכמים המיוחדים שנקבעו בחוק הבוררות בדבר דרכי האישור של פסק בורר וביטולו או מתן צו לעיכוב הליכים אינם חלים על הסכם בעל-פה (99-100 א').

(2) דרישת הכתב בחוק בוררות היא מהותית. הסכמת הצדדים להחיל על הסכם בוררות בעל-פה את הוראות חוק הבוררות למרות היעדר הכתב, אינה תופסת. גם שינוי הסכם שהחוק מחייב לעשותו בכתב חייב להיות בכתב. על-אף העובדה שהשתתפות בדיון ללא מחאה מהווה הסכמה מכללא לסמכות הבורר, הרי שהסכמה בעל-פה אינה יכולה לשנות את ההסכם בכתב (100 א'-ג').

(3) (אליבא דשופט א' גולדברג) גם אם דורש החוק כי הסכם הבוררות עצמו יהיה בכתב, אין שינוי צריך כתב. שינוי ההסכם אפשר שיהיה בהסכמה מפורשת של הצדדים שנעשתה בעל-פה לאחר מכן, ואפשר שהשינוי יהיה מכללא, כנלמד מהתנהגות הצדדים. אם הסכים צד לבוררות לשינוי בהסכם הבוררות (כין במפורש ובין מכללא), מנוע הוא מלטעון אחרי כן כנגד שינוי זה (102-103 א').

ב. (1) תורת ההשתק או המניעות נועדה למנוע תוצאות בלתי צודקות המתחייבות לכאורה על-ידי הדין, וזאת על-ידי השתקת המתדיינים מלטעון בבית המשפט טענות משפטיות ועובדתיות שהן נכונות כשלעצמן (100 ג'-ד').

(2) השתק מכוח מצג מונע צד מלהתכחש למצג שהוצג לפני צד אחר, אם אותו אחר הסתמך על המצג בתום-לב ובאופן סביר, ושינה עקב כך את מצבו לרעה. השתק כזה מוכר לא רק ביחס למצג של עובדה אלא גם לגבי עניין שכדין. כך ניתן להחיל השתק לגבי פירוש מסמך ודרישת כתב בחוזה מקרקעין ולגבי טענה בדבר בטלות הסכם על-פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 (100 ה'-ו').

(3) תורת ההשתק נקלטה במשפט הישראלי מן המשפט האנגלי באמצעות סימן 46 לדבר המלך במועצה על ארץ-ישראל, 1922. לאחר חקיקת חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, יש לראות בדיני ההשתק פן אחד של תורת תום הלב שנקבעה בחוק זה. התכחשות למצגים (וכן להבטחות) שניתנו במשאזומתן לכריתת חוזה או למצגים שנתנו יסוד להנחה כי נותנם לא יעשה שימוש בזכות המוענקת לו על-ידי החוק

- א. אי ההחלטה – בתוויה פגיעה בחובת תום הלב רקבועה בסעיפים 12 ו-39 לחוק החוזים (חלק כללי). לפגיעה זיכרון יתר אם זה סכלפני נעשה הסעיף (א) נקבל ההבטחה) שינה על פיו את מצבו לרעה (100 ו-101 א).
- א. (4) דין דוחה כסוי לחיל גם סכנת סילוב סעיף 39 הנ"ל עם סעיף 61(ב) לחוק, המטיל חובת תום הלב בביצוע כל פעולה מסוימת, גם כזו אשר אינה נוגעת ליהסיוס חוזיים, וזאת כאשר המצג (או ההבטחה) לא ניתנו במסגרת כשא ובהן לכריתת חוזה או במסגרת קיום של זכות הנובעת מחוזה או שימוש בה (101 א-ב).
- א. (5) בעל דין שהבטיח להתדיין לפני בורר שלישותו חרג מסמכותו, וזאת כלי למחות, הציג מצג בדבר הסכמתו להרחבת סמכות הבורר. הצד השני השתתף בהליכי הבוררות בהסתמכו על מצג זה, ובכך שינה מצבו לרעה. אילו היה יודע כי בעל דינו אינו מסכים להרחבה, היה זכאי לפנות לבית המשפט לקבלת הכרעה בסמכות הבורר, ולא היה מוציא היצאות ומשקיע זמן בדיון עקר. עליכן בעל הדין שלא מחה ברישוק מלשעון לבטלות הפסק עקב הוסה סמכות (101 ה-ו).
- ב. (6) במקרה דנן, לטענת ההבורר חרג מהסמכות שניתנה לו בהסכם הבוררות, המשיבה מושתקת מלשעון כנגד סמכות הבורר. לא זו בלבד שלא מחתה על התריגה מחאה ברורה וחד-משמעית בהודמנות הראשונה לאחר שהרג הבורר במסכותו, אלא הסכימה לשינוי הסכם הבוררות, ולכן היא מושתקת מלשעון בבית המשפט כי יש לבטל את הפסק בשל חריגת הבורר מסמכותו (102 ג-ה).
- ג. פסקי-דין של בית המשפט העליון שאוזכרו:

- ד. [1] ע"א 661/88 חיימוב נ' חמיד ואח', פ"ד מד (1) 75.
- [2] ע"א 280/66 רחנצוויג נ' בוחן. חברה לביטוח בע"מ, חיפה, פ"ד כא (1) 637.
- [3] ד"צ 13/67 "בחן". חברה לביטוח בע"מ, חיפה נ' רחנצוויג, פ"ד כב (1) 569.
- [4] ע"א 23/49 חברת י. צגלה ושות' בע"מ נ' א. חיות בע"מ, פ"ד ד 475.
- [5] ע"א 289/78 אשד ואח' נ' לובד ואח', פ"ד לג (1) 13.
- ה. [6] ע"א 151/85 י. רודן נ' א. רודן. קטין באמצעות אחו ואח', פ"ד לט (3) 186.
- [7] בג"צ 566/81 עמרני נ' בית הדין הרבני הגדול ואח', פ"ד לו (2) 1.
- [8] ר"צ 50, 34/87 ב"צ רבינוביץ נ' ד' רבינוביץ ואח'; ד' רבינוביץ נ' ב"צ רבינוביץ ואח', פ"ד מא (2) 398.
- [9] בר"צ 135/73 איטקוב ואח' נ' מפעלים חיימים ד"ר וינרט בע"מ, פ"ד כז (2) 813.
- ו. [10] רצ"א 300/89 ולקן חברה לבניין ועבודות עפר בע"מ ואח' נ' החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ, פ"ד סה (4) 497.
- [11] ע"א 205/56 צדוק חייקין בע"מ נ' עציון, פ"ד יא 1016.

- ז. בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (השופטת ש' סירוטה) מיום 13.9.92 בה"פ 434/92. הבקשה נדונה בערעור. הערעור נתקבל.

ר' שיוביץ – בשם המבקשים;
ב' חן – בשם המשיבה.

פסק־דין

השופטת ד' דורנר: 1. זוהי בקשת רשות לערער על פסק־דינו של בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו, שבו בוטל חלקית פסק בורר שניתן בהליכי הבוררות שהתקיימו בין המערערים למשיבה, המועצה המקומית תל־מונד (להלן – המועצה). מכוח סמכותנו על־פי תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד–1984, החלטנו לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות ערעור וכאילו הוגש ערעור על־פי הרשות שנתקבלה.

2. ואלה העובדות הצריכות לעניין: המערערים מחזיקים בנכס (קרקע ומבנה) בתל־מונד, המצוי בבעלות המועצה. הנכס נמסר להם בשנת 1972 על־ידי ישראל קופר. קופר חקר את הקרקע מן המועצה ביום 25.12.60 למשך 25 שנה. בחוזה החכירה התחייב קופר להקים על הקרקע מבנה ולנהל בו מסעדה ובית־קפה בלבד, כמתחייב מרישיון הבנייה שהוצא על־ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה. למועצה ניתנה הברירה בתום תקופת החכירה להאריכה או לשלם לחוכר את שווי המבנה והעסק.

3. מאז 27.7.83 מנהלים המערערים במבנה שהקים קופר עסק למכירת מצרכי מזון וחומרי ניקוי. העסק מתנהל ללא רישיון. ביום 25.4.84 הורשעו המערערים, יחד עם קופר, בבית־משפט השלום בנתניה בעבירה של שימוש בנכס ללא היתר. הם נצטוו לסגור את עסקם לא יאוחר מיום 1.7.88 אם לא יינתן להם היתר כחוק עד למועד זה. בתוך כך הלך קופר לעולמו. המועצה לא האריכה את תקופת החכירה, ובשנת 1990 דרשה מן המערערים לפנות את הנכס בטענה כי הם מחזיקים בו שלא כדין, ולשלם לה עבור התקופה שהחזיקו בו דמי שכירות ראויים. המערערים מצדם תבעו, כתנאי לפינוי הנכס, תשלום שווי המבנה והעסק.

4. הצדדים החליטו למסור את הסכסוך להכרעת הבורר, עו"ד נחמן אמיתי. בהסכם הבוררות, שנעשה ביום 6.7.90, הוסכם כי "תחומי הבוררות יוגדרו על ידי הצדדים על פי כתבי הטענות שלהם". מכתבי הטענות שהוגשו לבורר מתבקש כי הוא נדרש להכריע בשלושה עניינים: (א) זכות המערערים בנכס; (ב) זכות המועצה לדמי שימוש ראויים, תקופת החיוב וסכומם; (ג) שווי המבנה והעסק המתנהל בו ללא רישיון. במהלך הדיון צמצמו הצדדים את סמכותו של הבורר להכרעה בזכויותיהם ולמתן הוראות לשמאים כיצד להעריך את חיוכיהם, ואילו את קביעת גובה הסכומים (על־פי הנחיות הבורר) מסרו לשמאים.

5. הבורר נתן את פסקו ביום 3.8.90. בסעיף 5 לפסק, שהתייחס לצמצום סמכותו כאמור לעיל, נאמר:

"עם גמר הדיונים הגיעו הצדדים לידי הסכמה חשובה – הם הטילו עלי לתת החלטה עקרונית בדבר זכויות התובעים בנכס, ולהורות לשמאי כיצד להעריך את המגיע לה"ה עזרא (המערערים – ד' ד') – אם בכלל, ומה מגיע למועצה כדמי שימוש – אם בכלל. זאת ותו לאו".

א לגוף העניין קבע הבורר, כי המערערים החזיקו כדין בנכס עד לתום תקופת החכירה ביום 2.11.86, וכי עליהם לשלם מאותו היום דמי שימוש ראויים. הוא חייב את המועצה לשלם למערערים את שווי המבנה והעסק. ברם, אף שבהסכם הבוררות נאמר, כאמור, כי הבורר יקבע את שווי העסק ומנהלים המערערים, הבורר ראה שלא לעשות כן. וכך נאמר בסעיף 6 ה' לפסק:

ב "אני קובע כי על המועצה לשלם לנתבעים גם את שווי המבנה והעסק. השאלה היא – איזה עסק. אינני מוכן להורות על הערכת עסק שהוא מנוגד לחוקי הרישוי ומנוגד למטרת החזקה. אני מורה לשמאים שיעריכו את שווי המבנה ועסק של בית קפה ובסעדה קלה – אילו היה מתקיים במקום זה היום".

6. ביום 23.6.91 פנה באיכות המועצה, עו"ד חן, לבורר במכתב, וכך כתב:

ג "הריני בהכבד לפנות אליך בנדון בשם מרשתי המועצה המקומית תל מונד כדלקמן:

1. ביום 8.3.1991 ניתן על ידך פסק בורר אשר סיים לכאורה את הסכסוך במיטרת העקרוני, אך לא במישור הכספי-פרקטי, שכן הענין הכספי הועבר להכרעת שמאי הצדדים.

ד 2. כפי שהבנתי משמאי מרשתי, הוא בא בדברים עם השמאי שכנגד... דא עקא, כי לא הגיעו להסכמה בדבר שווי העסק כפי שהוגדר על ידך. השמאי של מרשתי קובע – ובצדק לטענתי – כי שווי עסק שאינו מנוהל אינו יכול להיות אחר מאשר אפס, שכן כאשר עסק מתנהל ניתן לבדוק את שווי העסק עפ"י ספריו, מחזור, הכנסות היצאות וכו' ואז ניתן לבדוק אם העסק מרוויח או מפסיד וכו'. כאשר עסק אינו מתנהל לא ניתן להעריך מה היה אילו, שכן גם אם היה מתנהל, אולי היה בלתי רווחי ויחויי אפס? השמאי שכנגד, מאידך, אינו קובע כל עמדה בענין ומשעה את תשובתו, ועל כן לא ניתן לסיים את הענין. לו לפחות היה קובע עמדתו – גם אם נוגדת – ניתן היה להחזיר את ההכרעה אליך או לשמאי שלישי.

ה 3. במצב דברים זה, כאשר הענין בלתי גמור, אודה לך אם תפעל לקדם העניין צ"ע לסיימו".

ז 7. בעקבות מכתב זה ובהסכמת המערערים, התחדש הדיון לפני הבורר. כל אחד מן הצדדים הגיש לבורר הוות'דעת של השמאי שמשעמו. אחרי שמיעת טענותיהם נתן הבורר ביום 29.12.91 החלטה, שבה קבע כי "שווי העסק של בית קפה ומסעדה קלה (כולל מוניטין) הוא 110.000 ש"ח". לאחר מתן החלטה זו, חזר ופנה עו"ד חן, וביקש להשלים את הפסק על-ידי חיוב המערערים בתשלום דמי שכירות ראויים כל עוד ממשיכים הם להחזיק בנכס. באיכות המערערים, עו"ד שויביץ, במכתב ששלח לבורר, כפר בסמכותו של הבורר להיזקק לבקשה זו. ברם, עליאף מהאמו החליט הבורר בבקשת עו"ד חן.

8. שני הצדדים פנו אל בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בבקשה לביטול הפסק המשלים (ה"פ 783/92). המועצה גם ביקשה לבטל את קביעתו של הבורר בדבר שווי העסק (ה"פ 434/92). במהלך הדיון הסכימו הצדדים כי ההחלטה המשלימה תבוטל וכי הדיון יוחזר לבורר, והמשפט התמקד בבקשת המועצה בה"פ 434/92 הנ"ל.

א

9. המועצה טענה כי הבורר חרג מהסמכות שניתנה לו בהסכם הבוררות לקבוע את שווי העסק המתנהל במבנה ללא רישיון. המערערים, מצדם, טענו כי המועצה לא מחתה על החלטתו של הבורר בדבר עריכה של שומת עסק של בית-קפה ומסעדה, והמשיכה להתדיין לפניו. היעדר ההתנגדות להחלטת הבורר היווה, כך טענו המערערים, הסכמה מכללא לסמכותו.

ב

בית המשפט המחוזי דחה את טענת המערערים ופסק כי סמכות הבורר נקבעת בהסכם הבוררות. וכך נאמר בפסק הדין:

"סמכויותיו של הבורר נקבעו בין הצדדים בהסכם הבוררות... סמכות הבורר (על פי ההסכם) היתה לקבוע שומת העסק הנוכחי ולא של עסק תיאורטי. משלא פעל כך חרג מסמכותו... לא ברור מדוע לא תקף ב"כ המבקשת את החלטת הביניים – אלא המתין עד לגמר הדיון. ברם, אין בכך כדי לחסום דרכה של המבקשת (המועצה)".

ג

10. המערערים טענו כי פסיקת בית המשפט המחוזי, שלפיה לעניין סמכות הבורר מכריע הסכם הבוררות הכתוב, הינה מוטעית. שינוי הסמכות יכול להיעשות גם בדרך של הסכמה מכללא של הצדדים. המועצה הסכימה להרחבת סמכותו של הבורר, בכך שלא מחתה על החלטתו כי יש להעריך את שווי העסק כבית-קפה. היא אף ביקשה משמאי מטעמה לערוך שומה על-פי ההחלטה הנ"ל, הגישה את השומה לבורר, ובא-כוחה השתתף בדיון שהתקיים לאחר הגשת השומות.

ד

ה

בתשובתה לערעור טענה המועצה כי לא נעשה הסכם בכתב המשנה את הסכם הבוררות, וכי על כל פנים בא-כוח המועצה, עו"ד חזן, מחה לפני הבורר "כבר בעת שהודע לו דבר הוראתו של הבורר לשמאים לשום את העסק על פי שווי עסק תיאורטי".

ו

11. השאלות הטעונות הכרעה הן שתיים: (א) האם ניתן לשנות הסכם בוררות בכתב על-ידי הסכם בעל-פה או הסכם מכללא; (ב) האם המועצה הייתה מושתקת מלטעון בבית המשפט טענת חוסר סמכות.

12. שינוי מכללא של הסכם בוררות: אין לו לבורר כוח שיפוטי, זולת הכוח שהקנו לו הצדדים בהסכם הבוררות. בכך נבדל הבורר מבית-משפט, שכוחו אינו תלוי בהסכמת הצדדים אלא קבוע בחוק. אמנם, הצדדים אינם מוגבלים בבחירת הצורה של הסכם הבוררות, ואף הסכם בוררות שנעשה בעל-פה הוא תקף (סעיף 39 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968; ע"א 661/88 חיימוב נ' חמיד ואח' [1], בעמ' 81; ס' אוטולנגי, בוררות דין ונוהל (דע-פורט, מהדורה 3, תשנ"א) 20). ברם,

ז

א

על-פי סעיף 1 לחוק הבוררות חלות הוראות חוק זה על הסכם בכתב בלבד. מכאן שההסדרים המיוחסים שנקבעו בחוק הבוררות בדבר דרכי האישור של פסק בורר וביטולו או מתן צו לעיכוב הליכים אינם חלים על הסכם בעל-פה (ע"א 661/88 [1], בעמ' 81–82; אוטולנגי, בספרה הנ"ל, בעמ' 486).

ב

13. דרישת הכתב בחוק הבוררות היא מהותית (אוטולנגי, בספרה הנ"ל, בעמ' 21). הסכמת הצדדים להתחיל על הסכם בוררות בעל-פה את הוראות חוק הבוררות למרות היעדר הכתב, אינה תופסת (ד' פרידמן, כ"ה, חזים (אבירם, כרך א, תשנ"א) 126–127). גם שינוי הסכם שהחוק מחייב לעשותו בכתב חייב להיות בכתב (השופט ברנזון בע"א 280/66 רוזנצוויג נ' "בוזחן", חברה לביטוח בט"מ, הפה [2], בעמ' 640. פסק-דין זה בוטל אמנם בד"נ 13/67 "בוזחן" חברה לביטוח בט"מ, הפה [3], בעמ' 640. נקבע כי דרישת הכתב באותו עניין לא הייתה מהותית. ואולם לא שניתנה החלטה בדבר תוקף שינוי הסכם שחלה עליו דרישת כתב מהותית. ראה גם פרידמן יכהן, בספרם הנ"ל, בעמ' 425).

ג

הדין הוא אפוא כי אף שההשתתפות בדיון ללא מחאה מהווה הסכמה מכללא לסמכות הבורר, הרי שהסכמה בעל-פה אינה יכולה ליטות את ההסכם בכתב.

ד

14. השתתפות מלטעון כי שינוי מכללא של הסכם בוררות אינו תקף: תורת ההשק (estoppel). הכנייה גם "מניעות", מועדה למנוע תוצאות בלתי צודקות המתחייבות לכאורה עלידי הדין – זאת על-ידי השתתפות של המתדיינים מלטעון בבית המשפט טענות משפטיות ועובדתיות שהן נכונות כשלעצמן (כ"ה, "דפוסי החווים ותום לב במשא ומתן: בין הכלל הפורמלי לעקרונות הצדקה" הפרקליט לו (תשמ"ז–ז"ז) 13, 22).

ה

השתתפות כזו נכונה – כמו זה שבענייננו – מונעת צד מלהתכחש למצג שהציג לפני צד אחר, אם אותו אחר הסתמך על המצג בתום-לב ובאופן סביר, ושינה עקב כך את מצבו לרעה (G. Spencer Bower and A. K. Turner. *The Law Relating to Estoppel by Representation* (London, 3rd ed., 1977) 4).

ו

במקרה, הכירה הפסיקה רק בהשתתפות מלהתכחש למצג של עובדה (ע"א 23/49 חברת י. צגלה ייבדי בע"מ נ. א. חית בע"מ [4], בעמ' 465), ואולם כיום מכירים גם בהשתתפות לגבי עניין שבדין. כך, השתתפות הוחל לגבי פירושי מסמך, ודרישת כתב בחווה מקרקעין (ע"א 289/78 אשד ואח' נ' ליבר ואח' [6], בעמ' 18) ולגבי טענה בדבר בטלות הסכם על-פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג–1973 (ע"א 151/86 דודן נ' א' דודן, קטין באמצעות אמו ואח' [6], בעמ' 193–194. ראה גם ג' סלי, "פגמים בכריתת חווה" פירוש לחוקי החווים (המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרב סאקר, ג' טדסקי עורך, תשמ"א) 55).

ז

15. תורת ההשתתפות נקלטה במשפט הישראלי מן המשפט האנגלי באמצעות סימן 46 לדבר הכללך בריעצה על ארץ-ישראל, 1922. ברם, לאחר חקיקת חוק החווים (חלק כללי),

א

תשל"ג-1973 (להלן – חוק החוזים), נראה לי כי יש לראות בדיני ההשתק פן אחד של תורת תום הלב שנקבעה בחוק זה. ההתכחשות למצגים (וכן להבטחות) שניתנו במשא ומתן לכריתת חוזה או למצגים שנתנו יסוד להנחה כי נותנם לא יעשה שימוש בזכות המוענקת לו על-ידי החוק או החוזה – מהווה פגיעה בחובת תום-הלב הקבועה בסעיפים 12 ו-39 לחוק החוזים. לפגיעה זו משקל יתר אם (כפי שנדרש בדיני ההשתק) זה שכלפיו נעשה המצג (או מקבל ההבטחה) שינה על-פיהם את מצבו לרעה. דין דומה עשוי לחול גם מכוח סעיף 61 (ב) לחוק החוזים, המטיל חובת תום הלב בביצוע כל פעולה משפטית, גם כזו אשר אינה נוגעת ליחסים חוזיים, וזאת כאשר המצג (או ההבטחה) לא ניתנו במסגרת משא ומתן לכריתת חוזה או במסגרת קיום של זכות הנובעת מחוזה או שימוש בה. עמד על כך השופט אלון בבג"צ 566/81 עמרני נ' בית הדין הרבני הגדול ואח' [7], בעמ' 10:

ב

"וכשם שלעניין דיני חוזים ובתחום המשפט המינהלי חלה מאז ומתמיד חובת ההתנהגות בתום-לב, במידה זו או אחרת, מכוח חקיקה שיפוטית בלבד... ועם חקיקתם של סעיפים 39 ו-61(ב) האמורים חזרה חובה זו ובאה לעולם, בהרחבת היריעה, כדבר חקיקתה של הרשות המחוקקת... כך לעניין עקרון המניעות שלפנינו: הורתו ולידתו של עיקרון זה בפסיקתו של בית-משפט זה, לאחר מאן מעוגן הוא בסעיף 7 (ב) (4) לחוק בתי המשפט, ועם חקיקתם של סעיפים 39 ו-61(ב) האמורים חזר ובא לעולם כחלק מעקרון ההתנהגות בדרך מקובלת ובתום-לב שבכלל המערכת המשפטית בישראל".

ג

ד

גם השקפתו של פרופסור פרידמן היא, כי תורת ההשתק מאגדת מקרים המהווים חטיבה של תורת תום הלב, וכי ניתן לעגן את תורת ההשתק בהוראות תום הלב שבחוק החוזים (ד' פרידמן, "עוד לפרשנות החקיקה הישראלית החדשה" עיוני משפט ה' (תשל"ו-ל"ז) 463, 488-489).

ה

16. בעל דין שהמשיך להתדיין לפני בורר שליטתו חרג מסמכותו, וזאת בלי למחות, הציג מצג בדבר הסכמתו להרחבת סמכותו של הבורר. הצד השני השתתף בהליכי הבוררות בהסתמכו על מצג זה, ובכך שינה מצבו לרעה. אילו הוא היה יודע כי בעל דינו אינו מסכים להרחבה, הוא היה זכאי לפנות לבית המשפט לקבלת הכרעה בסמכות הבורר, ולא היה מוציא הוצאות ומשקיע זמן בדיון עקר. עליכן בעל הדין שלא מזה מושתק מלטעון לבטלותו של הפסק. עמדה על כך השופטת בן-פורת בר"ע 34/87, 50 ב"צ רבינוביץ ואח' נ' ד' רבינוביץ ואח'; ד' רבינוביץ נ' ב"צ רבינוביץ ואח' [8], בעמ' 401:

ו

"...המשיב לא העלה את טענת חוסר הסמכות לפני הבוררים וגם לא מיחה על המשך הדיון לפנייהם ולפיכך הוא מנוע מלהעלותה בשלב הזה...".

ז

אף בבר"ע 135/73 איסקוב ואח' נ' מפעלים כימיים ד"ר ויגרט בע"מ [9], בעמ' 817, השתיק השופט וזסמן טענה כי הבורר חרג מסמכותו. וכך אמר:

"אם המבקשים לא השמיעו דברם כלפי תביעה זו בפני הבורר, מפני שכפרו

בסמכותו לדון בה, אין להם אלא להלין על עצמם. הבורר הודיעם בפירוש שגם תביעה זו עומדת לבירור, ולמבקשים היתה שעת כושר להגיב עליה, ולו רק להלופין, תוך שמירת טענתם שהעניין לא נמסר להכרעת הבורר".

א

סיכמה את ההלכה פרופסור אוטולנגי, בספרה הנ"ל, בעמ' 438:

"...צילת ביטול עומדת לצידו (של צד להלין בוררות – ד' ד'), אך טענת מניעות – נגדה. לא העלה טענת חוסר הסמכות בפני הבוררים וגם לא מיחה על המשך הדיון בפניהם – יהיה מנוע מלעלות טענה זו בשלב של בקשה לביטול הפסק".

ב

יראה גם: דע"א 300/89 ולקר חברה לבניין ועבודות עפר בע"מ נ' החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ (10), בעמ' 1516; פרידמן וכהן, בספרם הנ"ל, בעמ' 469; F. Russell, *On The Law of* Arbitration (London, 20th ed., by A. Walton and M. Vitoria, 1982) 267.

ג

17. יוסאן לענייננו. הערכאה הראשונה צדקה בקביעתה כי הבורר חרג מן הסמכות שניתנה לו בהסכם הבוררות. אולם אין לקבל את מסקנתה, כי המועצה אינה מושתקת מלטעון כנגד סמכות הבורר. לא זו בלבד שהמועצה לא מתחה על החריגה "מחאה ברורה וחד-משמעית... בהוראות הראשונה לאחר יתרג הבורר מסמכותו..." (הנשיא שמגר בדע"א 300/89 [10], בעמ' 1516). אלא מן הסתם יצויטט לעיל, שכתב באיכותה, מתבקש כי היא הסכימה לשינוי הסכם הבירור. כאמור, ע"ד חן ביקש מהבורר, שסיים מלאכתו שלושה חודשים קודם לכן ובגדר פסקו חרג מסמכותו בעניין הנדון, כי ישוב לקיים הליכי בוררות וכי יקבע את שווי העסק על-פי העיקרון שהתווה בפסק בהחריגה מהסכם הבוררות. ע"ד חן גם ציין כי השמאי מטעמו העריך את שווי העסק כאפס, ואילו השמאי של המערערים מתמהמה. נראה כי ע"ד חן האמין שדרך השומה שקבע הבורר בהחריגה מהסכם הבוררות אך נוחה יותר למועצה. בנסיבות אלה, ומשהניתה המועצה להליכי הבוררות, שלשיטתה היו ללא סמכות, להמשיך ולהתגלגל חודשים אחדים ולא הראתה כל סימן כי כוונתה היא בסמכות לקיימם, ברור הוא כי המועצה הייתה מושתקת מלטעון בבית הדשפט כי יש לבטל את הפסק בשל חריגת הבורר מסמכותו.

ד

ה

18. מטעמים אלה אני מציעה לקבל את הערעור, לבטל פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בה"פ 434/92 ולאשר את פסק הבורר. כן אני מציעה לחייב את המועצה לשלם למערערים היצאות משפט בסך 10,000 ש"ח.

ו

הנשיא ח' שמגר: אני מסכים.

ז

השופט א' גולדברג: גם אם דורש החוק כי הסכם הבוררות עצמו יהיה בכתב, אין שינוי צריך כתב. שינוי ההסכם אפשרי יהיה בהסכמה מפורשת של הצדדים שנעשתה בעל-פה לאחר מכן, ואפשר שהשינוי יהיה מכללא, כנלמד מהתנהגותם של הצדדים. כפי שנאמר בע"א 205/56 צדקס ח"צ"ק בע"מ נ' עזיזון [11], בעמ' 1017. "אין כל שינוי ושינוי בהיקף הבוררות

א

מחויבים להיעשות דוקא בכתב" (וראה גם אוטולנגי, בספרה הנ"ל, בעמ' 23–24). עניינו של ע"א 280/66 [2] אינו בחוק הבוררות אלא בסעיף 2 לחוק הביטוח העותמני. ולא זו בלבד שאין בהכרח ללמוד לענייננו גזירה שווה בין שני הדינים, אלא שבר"נ 13/67 [3] שונתה ההלכה בדבר מהות דרישת הכתב לגבי סעיף 2 הנ"ל, כפי שציינה חברתי, השופטת דורנר.

ב

פשיטא, על-כן, כי אם הסכים צד לבוררות לשינוי בהסכם הבוררות (כין במפורש ובין מכללא), מנוע הוא מלטעון אחרי כן כנגד שינוי זה.

לפיכך מסכים אני לתוצאה אליה הגיעה חברתי, השופטת דורנר, בדיון שלפנינו, שכן הסכימה המועצה מכללא להרחבת סמכותו של הבורר.

הוחלט כאמור בפסק-דינה של השופטת דורנר.

ג

ניתן היום, ד' בסיון תשנ"ג (24.5.93).

ד

ה

ו

ז